

مادة القرض الاستهلاكي

الدرس الأول

- تعرض المشرع الجزائري للقرض الاستهلاكي في القانون المدني المواد 450 إلى 458.

و في قانون حماية المستهلك ضمن تعديل قانون 03-09.

و في قانون القرض و النقد الجزائري عقد القرض بصفة عامة، أمر رقم 11-03 معدل و متم بالأمر رقم 04-10 المؤرخ في 26 أوت 2010.

و ضمن النص الخاص، و هو المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المؤرخ 12 مايو سنة 2015 يتعلق بشروط و كيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي.

سنتعرض لكل هذه النصوص و الاختلافات الموجودة بينهم و مجال تطبيق كل نص.

- نتعرض أولا للقانون المدني، باعتباره الشريعة العامة فعقد القرض هو عقد ينطبق عليه جميع النصوص الواردة في النظرية العامة للعقد إلا فيما تعرض إليه المشرع في النص الخاص فلا شك أن النص الخاص يقيد العام.

و المشرع أدرج القرض الاستهلاكي في الفصل الرابع من الباب السابع في القانون المدني و ضمن العقود الناقلة للملكية و هذا من أهم مميزات هذا العقد كما سنرى.

و يبدو الاختلاف في مضمون عقد القرض الاستهلاكي الواردة في القانون المدني عما ورد في قانون القرض و النقد و قانون حماية المستهلك إذ يخص القانون القرض بمفهوم prêt ، بينما في قانون حماية المستهلك و قانون القرض و النقد فهو أوسع من ذلك إذ يقصد به الائتمان crédit ، و يشمل عقود أخرى غير القرض كالبيع والتقسيط.

إذ تنص المادة الثالثة (03) فقرة أخيرة من قانون حماية المستهلك :

"والمفروض أن يطلق على العقد في القانون المدني القرض للاستهلاك ليكون أكثر دقة.

و العبرة في ذلك أن جوهر القرض في القانون المدني أنه للاستهلاك بالنظر الى محل عقد القرض، بينما في قانون المستهلك الطرف المتعاقد المقترض يشترط أن يكون مستهلك.

سأتناول أولاً تعريف عقد القرض في القانون المدني، تميزه عن باقي القوانين، مميزاته ثم آثاره.

تعريف عقد القرض في القانون المدني :

ينص المشرع في المادة 450 مدني : "قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، و القدر، و الصفة".

فعقد القرض هو عقد يضع فيه المقترض شيء مثلي تحت تصرف المقترض يستعمله على أن يرد مثله بعد انتهاء عقد القرض.

فمحل عقد القرض هي أشياء قابلة للاستهلاك بحيث باستهلاكها يتعذر على المقترض ردها عينا على خلاف عقد العارية كما سنرى.

لقد عرف المشرع الأشياء القابلة للاستهلاك و الأشياء المثلية في القانون المدني.

الأشياء القابلة للاستهلاك و الأشياء غير القابلة للاستهلاك:

تنص المادة 685 مدني على ما يلي: "الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها.

و يعتبر قابلاً للاستهلاك كل شيء يكون جزءاً من المحل التجاري و هو معد للبيع".

فالأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها و إنفاقها.

و استهلاكها قد يكون مادياً أو قانونياً.

و يؤدي الاستهلاك المادي، في حالة الانتفاع بالشئ إلى هلاك أو نفاذ مادته، كمن يأكل شيئاً أو يشرب ربا. أما الاستهلاك القانوني فهو يتحقق بخروج الشيء من يد صاحبه دون أن يؤدي ذلك إلى هلاكه مادياً كإنفاق النقود مثلاً.

أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي التي يتكرر استعمالها دون أن تستهلك و تنفذ، مثالها المنازل، الكتب. و تقسيم الأشياء إلى أشياء تستهلك و أشياء لا تستهلك يرجع إلى طبيعة الأشياء ذاتها، فمنها ما يتحمل تكرار الاستعمال، و منها من لا يتحمل ذلك، غير أن إرادة الإنسان تستطيع التعديل من هذا التقسيم يجعل الشيء القابل للاستعمال المتكرر شيئاً قابلاً للاستهلاك، و ذلك عن طريق تخصيصه، فكثراً من السلع تقبل الاستعمال المتكرر إلا أن عرضها للبيع يحولها إلى أشياء غير قابلة للاستعمال المتكرر، إذ تستهلك هذه الأشياء استهلاكاً قانونياً.

و من جهة أخرى فالفواكه و النقود أشياء قابلة للاستهلاك بطبيعتها لكنها تصبح غير قابلة للاستهلاك إذا أعدت للعرض في معرض.

و تكمن أهمية هذا التقسيم في أن بعض العقود لا ترد إلا على الأشياء القابلة للاستهلاك، و بعض العقود الأخرى لا ترد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك.

1- هناك عقود لا يمكن أن يكون محلها إلا أشياء غير قابلة للاستهلاك، مثل الانتفاع بشيء لمدة معينة، و كذلك الإيجار و العارية، فالمستأجر و المستعير يستعمل كل منها شيئاً مملوكاً للغير، على أن يرد له لصاحبه بعد مدة معينة، و كذلك حق الانتفاع، إذ المنتفع ينتفع بالشيء مدة معينة على أن يرد له لمالكه، إلا أنه إذا كانت الأموال المنتفع بها قابلة للاستهلاك فيتحول حق الانتفاع إلى شبه حق الانتفاع.

2- كما أن هناك بعض عقود لا يتصور أن ترد إلا على الأشياء القابلة للاستهلاك، ففي عارية الاستهلاك يأخذ الشخص من الآخر شيئاً لينفع به عن طريق استهلاكه، فمن يستعير كمية من السكر، فهو لا يلتزم برد عين الشيء الذي استعاره و إلا انتفت الفائدة من هذه الإعارة، ففي عقد القرض الاستهلاكي، يستعمل المقرض النقود المقترضة على أن يرد نفس المقدار، فهو يرد إذن نفس المقدار و ليس النقود التي اقترضها ذاتها.

الأشياء المثلثة و الأشياء القيمة:

تنص المادة 686 مدني على ما يلي: "الأشياء المثلثة هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء و التي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقياس، أو الكيل، أو المقياس".

فالأشياء المثلثة أو المعنية بالنوع هي التي تقوم مقام البعض، و يقال أن الأشياء المثلثة هي عادة تلك التي لا يمكن أن تعين إلا بتعيين نوعها فيقال مثلا قنطار من القمح متوسط الجودة.

أما الأشياء المعنية بالذات أو القيمة، فهي التي لا يقوم بعضها مقام البعض، إذ لا يمكن أن تتحد في الصفات كالسيارات مثلا و العقارات.

و لا يتوقف اعتبار الأشياء من المثلثات أو القيميات على طبيعتها فقط، و إنما لإدارة الأطراف دورا تلعبه في ذلك أيضا فبيع شيء مثلي بيعا جزافا يعتبر بيعا لشيء معين بالذات، كما أن النقود رغم أنها من المثلثات فإنها قد تعتبر من الأشياء القيمة في حالة استعارتها لعرضها في معرض في معرض مدة معينة ترد بعدها.

كما أن صانع السيارات إذا باع سيارة من الطراز المتوفر في السنة الجارية، فيكون ملزما بتقديم أية سيارة من هذا الطراز، و يعتبر بيع الشيء مثلي رغم أن السيارة في الأصل تعتبر شيئا قيميا.

و تجدر الإشارة إلى أنه رغم تدخل إرادة الأطراف في تحديد طبيعة بعض الأشياء في حالات معينة إلا أن هناك أشياء تعتبر دائما من المثلثات، و هي الأشياء التي تباع بالكيل، أو العدد، أو الوزن، فمن يتعاقد مثلا علي شراء ألف طن من القمح الممتاز لا يمكنه حين الرد الرفض إذا قدمت له هذه الكمية من النوع المتفق عليه بحجة أنه ليس هذا هو المبيع المتفق عليه.

و تتجلى أهمية هذا التقسيم في:

1- من حيث انتقال الملكية: فإذا كان الشيء مثليا أي معينا بالنوع فإن ملكيته لا تنتقل إلا بعد الإفراز، أما إذا كان معينا بالذات فإن ملكيته تنتقل بمجرد انعقاد العقد، دون حاجة لأي إجراء.

2- من حيث استحالة التنفيذ: إذا كان الشيء معينا بالذات و هلك بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، برئت ذمته من الالتزام.

أما إذا كان المبيع معينا بالنوع و هلك، فلا يتحلل البائع من التزاماته، لأن المثلثات لا تهلك، فهي تقوم مقام بعضها فيجب على البائع تنفيذ إزامه بشيء من نفس الشيء المبيع الهالك.

3- من حيث الوفاء: إذا كان محل الالتزام شيئاً قيمياً، فالوفاء بالالتزام يتم بإعطاء نفس الشيء المتفق عليه في العقد و لا يجبر الدائن على قبول غيره.

أما إذا كان محل الالتزام مثلياً، فإن المدين يبرأ من التزامه إذا هو أدى أو قدم شيئاً من نفس النوع و بالقدر و بالصفة المتفق عليها في العقد.

4- من حيث إجراء المقاصة: فلا تتحقق المقاصة القانونية بين التزامين إلا إذا كان محلها شيئاً مثلياً متحداً في النوع و الجودة، فمثلاً إذا كان شخصاً الأول مدين للثاني بتسليم سيارة معينة و الثاني مدين للأول بتسليم عقار بنفس قيمة السيارة، فإن المقاصة لا تتم بين الالتزامين.

و يلاحظ أنه غالباً ما تعتبر الأشياء المثلية قابلة للاستهلاك أما الأشياء المعينة بالذات فتعتبر غير قابلة للاستهلاك، إلا أنه قد يحدث أن يكون الشيء معيناً بنوعه و لكنه يكون غير قابل للاستهلاك، كالأدوات الصناعية مثلاً و الآلات و جميع الأشياء المصنوعة بالسلسلة *les choses fabriquées en série*.

كما أنه قد يحدث أن يكون الشيء قابلاً للاستهلاك رغم أنه معين بذاته، كالثمار التي لا توجد مثلها « *exceptionnel* » مثال ذلك مشروب أصبح نادراً و فريداً من نوعه.

و يلاحظ أن هذه المسألة راجعة إلى تدخل إرادة الإنسان في تحويل الأشياء.

فالقرض الاستهلاكي محله أشياء قابلة للاستهلاك إذ لو لم تستهلك بالاستعمال لأمكن ردها عينا و نكون إذن أمام عقد عارية أو قرض الاستعمال و قد يتفق المتعاقدان على رد المثل و لو أن محل العقد أشياء لا تستهلك بالاستعمال فاعتبار الأشياء قابلة للاستهلاك و غير قابلة للاستهلاك ليس من النظام العام إذ لا تمس توازن اقتصادي أو اجتماعي.

فيمكن الاتفاق على اعتبار أشياء غير قابلة للاستهلاك و غير قابلة للاستهلاك و هناك من يرى أنها بالتالي تخضع للنصوص الخاصة بالقرض الاستهلاكي و لكن خضوعها لذلك يظل خاضع للسلطة التقديرية للقاضي إذا لم يحدد المتعاقدان أحكامها بدقة و لهذا اختلف البعض في تكييف عقد كان محله أشياء غير قابلة للاستهلاك و مطالبة أحد المتعاقدان رد المثل فقط مادام مثيلها موجود في السوق و هذا بصدد عقد ثم بين مورد للبنزين و قد قدم براميل لوضع البنزين فيها و عند

إنهاء العقد أو فسخه طالب من المتعاقد معه صاحب محطة البنزين باسترجاع البراميل المقدمة للاستعمال عينا باعتبار ذلك عقد عارية لهذه البراميل و رفض صاحب المحطة ذلك لأن استرجاعها عينا يكلفه نفقات باهظة و عرض استرجاع مثلها فقط و هنا ثار مشكل تكييف هذا العقد فهناك من كيفه أنه عقد مقايضة و اكتفي البعض بتطبيق قواعد أخرى في قانون المنافسة لتجنب تطبيق قواعد القرض.

مما يبرز أهمية المحل في عقد القرض الاستهلاكي و لو أننا نتقبل فكرة أن المتعاقدين يمكنهم اعتبار أشياء غير قابلة للاستهلاك أنها استهلاكية يرد مثلها فقط أو العكس ترد ذاتها و لو كانت من الأشياء القابلة للاستهلاك كعرض منتجات زراعية في معارض ترد إلى أصحابها عينا بعض القرض إلا أنه من الصعوبة تطبيق قواعد القرض الاستهلاكي عليها إذا لم تتجه إرادة المتعاقدين صراحة عندنا بإدراج البند القاضي بالاسترداد المثل يجعل منها بالضرورة قرض استهلاكي.

الدرس الثاني: مميزات عقد القرض الاستهلاكي

سأبرز أهم مميزات القرض الاستهلاكي و الأثر المترتب على ذلك.

أولاً: عقد ناقلاً للملكية:

أدرج المشرع عقد القرض الاستهلاكي ضمن العقود الناقلة للملكية ومن أهم مميزات عقد القرض الاستهلاكي أنه ناقل للملكية و ما دمننا بصدد المثليات فيطبق عليها القواعد العامة بحيث تنتقل الملكية بالإفراز وفقاً للمادة 166 من القانون المدني: "إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء".

و بما أن الملكية تنتقل إلى المقترض، فالمقترض يكون له مركز دائناً فإذا أفلس المقترض فلا يستطيع استرداد ما اقترضه و لكن فقط الدخول كدائن عادي في تفضيله المقترض.

كما أن المقترض يستطيع التصرف في محل القرض و يعد تصرفه تصرف مالكا يرتب الآثار القانونية و لا يمكن اعتباره تصرفاً في ملك الغير.

عقد القرض في القانون المدني رضائي:

إن المشرع في القانون المدني لم ينص على شكل خاص لعقد القرض، فهو رضائي، فيكفي تراضي الطرفان لانعقاد صحيح، مع الملاحظة أن الكتابة مطلوبة للإثبات فقط

إذ تنص المادة 333 مدني: "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

و يقدر الالتزام باعتبار قيمة وقت صدور التصرف القانوني و يجوز الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الإلزام على 100.000 دينار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.

و إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري و لو كانت هذه الطلبيات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، و كذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 10.000 دينار جزائري".

و إذا كانت الكتابة غير مطلوبة للانعقاد و لكن لا يمنع أن يلجأ إليها المتعاقدان بل يمكنهما أن يتفقا على إصباغ العقد في قالب رسمي و يلاحظ أن الكتابة مطلوبة في قانون الاستهلاك و ستعرض لذلك لاحقا.

إلا أن المشرع في القانون المدني لم ينص على ذلك فيبقى العقد الغير مكتوب صحيح، و إذا كان طابع المجاني يجعله منه تصرف خطير إذ عدم تسديد المقرض لمبلغ القرض محتملا و لكن المشرع اكتفى في القانون المدني باشتراط الكتابة للإثبات.

و الملاحظة أن بعض القوانين مثل القانون الفرنسي يعتبر عقد القرض عقد عيني و يعتبر التسليم ركن في العقد ويبررون ذلك أن المقرض يدرك خطورة التصرف بالتسليم.

ثانيا: عقد بلا عوض أو مجاني:

ينص المشرع صراحة في القانون المدني المادة 454 على ما يلي: "القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر و يقع باطلا كل نص يخالف ذلك".

و إذا كان المشرع وضع استثناء بصدد المؤسسات المالية المواد 455-456 مدني:

- المادة 455 مدني: "يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحددها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار".

- المادة 456 مدني: "يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحددها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".

لكن القرض بين الأشخاص يكون دائما بدون عوض أو مجاني و إذا اتفق المتعاقدان على نسبة معينة أو عوض معين وقع البند باطلا و يبقى العقد صحيحا،

و يعد هذا لمبادئ الشريعة الإسلامية إذ تضمنت سور متعددة في القرآن الكريم على
تحريم الربا والحث على القرض الحسن. - سأتناول هذا بالتفصيل لاحقا -

فيعد القرض بين الأشخاص مجاني و لو كان المقرض يجني منفعة أدبية أو معنوية.
وأدرجه بعض المؤلفين ضمن عقود التبرع و لكن يظل عقد القرض يختلف عن
التبرعات مثل الهبة التي يتم فيها نقل الملكية بصفة نهائية، بينما يتضمن القرض
الالتزام بالرد،

لهذا لا يمكن تطبيق بصدده المادة 776 مدني: "كل تصرف قانوني يصدر عن
شخص في حالة مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت،
و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطي الى هذا التصرف.

وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم و هو
في مرض الموت و لهم إثبات ذلك بجميع الطرق، و لا يحتج على الورثة بتاريخ
العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.

إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف
صادرا على حسب التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا
مالم توجد أحكام خاصة تخالفه".

أما بصدد أهلية المقرض فقد تضمن نص قانون الأسرة 88 قانون الأسرة: "على
الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا
لمقتضيات القانون العام.

وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:

- 1- بيع العقار، وقسمته، ورهنه، إجراء المصالحة،
- 2- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،
- 3- استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة،
- 4- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد
بلوغه سن الرشد. "

وهذا النص يطبق في حالة الوصاية، المادة 95 قانون الأسرة، و في حالة التقديم المادة 100 قانون الأسرة، و بالتالي لا يمكن للقاصر الإقراض إلا وفقا لما نص عليه القانون.

عقد القرض: عقد ملزم لجانين:

ينص المشرع في المادة 55 قانون مدني على ما يلي: "يكون العقد ملزما للطرفين، متي تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا".

ولا شك أن المقرض ملزم بتسليم محل القرض المادة 451 و المقرض ملزم بالرد المادة 450.

و لكن هذه الالتزامات لا تنشأ في وقت واحد أو غير متقابلة مثلما هو الحال في عقد البيع و الإيجار.

و لهذا لا يخضع لأحكام العقد الملزم لجانين أو لا أهمية لتطبيقها فإذا كان المقرض نفذ إزامه وامتنع أو تأخر المقرض عن الرد فلا أهمية لطلب فسخ العقد وفقا للمادة 119 كما لا يمكن للمقرض الدفع بعد التنفيذ لان الالتزام للمقرض (المادة 123) بالرد لاحقا عن التزام المقرض بالتسليم.

الدرس الثالث: التمييز بين القرض الاستهلاكي و ما يشته به

الفرق بين القرض الاستهلاكي و شبهه حق الانتفاع:

التقارب بين العقدين قائم في أن لكل من المنتفع و المقرض حق استعمال الشيء و الالتزام بالرد و خاصة أنه بصدد شبه حق الانتفاع محله أشياء قابلة للاستهلاك المادة 851 مدني: "إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً و جب جرده و لزم المنتفع تقديم كفالة به فإن لم يقدمها بيع المال ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها، و للمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك بشرط أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع، و له نتاج المواشي بعد أن يعرض منها ما هلك من الأصل بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.

ويمكن إدراج مثال عن هذا الحبوب في الأراضي الزراعية فقد يقع التشابه بين ما إذا كنا أمام عقد قرض استهلاكي الذي يترتب التزامات و حقوق شخصية أم حق انتفاع و لكن يظل الفرق قائماً باعتبار حق الانتفاع حق عيني، يمكن المنتفع من ممارسة سلطته على العين دون وساطة أي شخص.

ويشمل حق الانتفاع، الاستعمال و الاستغلال و ينتهي بموت المنتفع أو بانقضاء الأجل المعين له، (المادة 852)، كما ينتهي بهلاك الشيء (المادة 853) أو ينتهي كذلك بعدم استعمال لمدة خمس عشرة سنة (المادة 854).

و يرد حق الانتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات والآلات والمواشي ... كما يرد على الأموال غير المادية كحق المؤلف، و حق المخترع.

و حق الانتفاع يخول للمنتفع حق استعمال الشيء لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي، و يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء ورده لصاحبه عند نهاية الانتفاع و هذا ما نصت عليه المادة 849 مدني.

كما أن للمنتفع حق استغلال العقار، فتكون له ثماره المدنية و الطبيعية و هذا ما نصت عليه المادة 846 مدني بينما منتجات الشيء تكون لمالك العقار و ليس للمنتفع لان استخراج المنتجات ينقص من أصل الشيء.

فمثلا في الانتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان، و الصوف و ناتج المواشي، هذا بعد ما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة (المادة 851 مدني في شطرها الأخير).

و يشمل استغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها، و هو ملزم بالمحافظة علي المتجر و بصفة عامة يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء حسبما أعد له و إدارته إدارة حسنة و هذا ما نصت عليه المادة 1/849 مدني.

كما يلتزم المنتفع بصيانة الشيء و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيء (المادة 848 مدني).

و فوق ذلك يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء المنتفع به و يرده إلى مالكة عند انتهاء مدة الانتفاع و إذا كان الشيء محل الانتفاع من الأشياء القابلة للاستهلاك و تم استهلاكها فعلا من طرف المنتفع و يجب عليه أن يرد بدلها فقط للمالك عند انتهاء الانتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الانتفاع.

ولا يجوز للمالك أن يقوم بفعل ما من شأنه تعطيل حق الانتفاع أو الإنقاص منه.

ولما كان حق الانتفاع حقا متجزأ عن حق الملكية فانه يسمح لصاحبه باستعمال و استغلال الشيء فقط دون حق التصرف إذ يظل لمالك الشيء (و هو ما يسمى بمالك الرقبة) حق التصرف في الشيء باعتباره ملكا له.

ويجوز للمنتفع التصرف في حقه (الانتفاع) و ليس في ملكية الشيء محل الانتفاع إلا أن تصرفه هذا محدود بمدة حياته أو بمدة الانتفاع.

و هذا التحديد ضروري بالنسبة لحق الانتفاع حتى لا يكون الانتفاع قيذا أبديا علي الملكية. بينما يظل عقد القرض يرتب وينشأ حقوق شخصية.

الفرق بين القرض الاستهلاكي و المقايضة:

يتعرض المشرع للمقايضة في المواد 413 و 415 فمحل عقد المقايضة منقولات و عقارات دون فرق فلم يستبعد المشرع في المادة 413 إلا النقود.

والمقايضة عقد ينقل الملكية مثل القرض الاستهلاكي مما يثار التشابه بين العقدين لكن جوهر التفرقة.

إن عقد المقايضة ليس حتماً أشياء مثلية و بالتالي إذا كان قرض الاستهلاك يرد المثل (في النوع و المقدار و الصفة) في المادة 450 مدني، ففي المقايضة قد يكون بين شيئين مختلفين تماماً.

فلا يوجد مقايضة إذا كان الشئان المتبادلان متماثلان.

و إدراج هذه التفرقة مهمة في إطار اختلاف الأحكام المطبقة على العقدين إذ تلعب أحياناً إرادة الأطراف دور فقد يتم الاتفاق على عقد مقايضة في أشياء قابلة للاستهلاك بطبيعتها فتطبق أحكام المقايضة إذ كان الاتفاق صريح بذلك.

الفرق بين القرض الاستهلاكي و عقد العارية:

القانون المدني يفرق بين القرض الاستهلاكي و العارية أو قرض الاستعمال في الأحكام و لعل المصطلح الفرنسي يدل صراحة

على التشابه بينهما باعتباره يطلق عليه المشرع *prêt à usage* .

و التشابه بين العقدين يكمن في الجانب المجاني للعقدين المادة 538 مدني نص: "العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال".

كما أن المادة 454 مدني: "القرض بين الأفراد يكون دائماً بدون اجر و يقع باطلاً كل نص يحالف ذلك".

و هذا الجانب المجاني يؤدي حتماً إلى التخفيض من التزامات المقرض لهذا تحيل المادة 452 من القانون المدني: "إذا استحق الشيء فإن أحكام المادة 538 و ما بعدها و الخاصة بالعارية هي التي تطبق"، بصدد القرض الاستهلاكي إلى النص الخاص بالعارية فيما يتعلق بالضمانات التي يضمنها المقرض.

و إذا كان الفرق بين العقدين يظهر في اختلاف محل كل منهما فعقد العارية يرد على منقولات معينة بالذات أو عقار فالمشرع ينص صراحة على أن يكون الشيء غير قابل للاستهلاك المادة 538 من القانون المدني.

لكن سبق أن تعرضنا أن هذا النص ليس من النظام العام فيمكن للأطراف الاتفاق على اعتبار أشياء قابلة للاستهلاك محل عارية كما بخصوص المعارض التي

تضع منتج معين كالنقود و يتم الاتفاق على ردها عينا و لكن يجب في هذه الحالات الاستثنائية الاتفاق الصريح على ذلك.

و الاختلاف الوارد بين العقدين هو أن المعير يظل مالكا لمحل الإعارة و لا يكون للمستعير سواء حق استعمال الشيء فالنص صريح في المادة 538 مدني: "العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أ، يرده بعد الاستعمال"، يخول للمستعير حق الاستعمال (على خلاف العارية و في الفقه الإسلامي يكون للمستعمر ملكية المنفعة إذ تخوله حق الانتفاع).

و باعتبار المعير يظل مالكا فيستطيع رفع دعوى استرداد كما يمكنه المطالبة بالرد دون اعتبار الأجل الممنوحة في حالات معينة منصوص عليها في المادة 547 مدني: "يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:

- إذا عرضت له عاجلة للشيء لم تكن متوقعة،
- إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه،
- إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير".

كما أن لدائن المعير الحق في التنفيذ على محل العارية في يد المستعير. أما بصدد القرض الاستهلاكي فتنقل الملكية للمقترض و لا يمكن لدائن المقرض الحجز على محل القرض في يد المقرض كما أنه في حالة الإفلاس إذا كان المقرض تاجرا لا يمكن أن يدخل محل القرض تفليسة المقرض. كما أن في حالة هلاك محل القرض فإن المستعير في الإعارة لا يسأل إلا في حالة عدم بذل عناية الرجل العادي.

رغم أن المادة 544 مدني تضمنت خطأ مادي قد يؤدي إلى اللبس بصدد هذه المسألة إذ تنص على ما يلي: "على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط أن لا يكون اهتمامه به أدنى من عناية الرجل المعتاد.

و في كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو كان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينفذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختر أن ينقذ ما يملكه".

بينما في المادة 451 مدني بصدد القرض الاستهلاكي تنص صراحة: "يجب على المقرض أن يسلم إلى المقرض الشيء الذي يشتمل عليه العقد و لا يجوز له أن يطالبه برد نظيره إلا عند انتهاء القرض. و إذا تلف الشيء قبل تسليمه إلى المقرض كان الإلتلاف على المقرض".

و بمفهوم المخالفة فإن هلاك الشيء بعد التسليم يكون على المقرض و ما يبرر هذا هو اعتبار المقرض مالكا وهذا على خلاف العارية تماما.

الفرق بين القرض الاستهلاكي و الشركة:

تنص المادة 416 مدني على ما يلي: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيين أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك".

و يبدو الفرق بين القرض الاستهلاكي و الشركة واضح إنما تدق التفرقة عندما يقدم الشريك حصة مالية في الشركة فإذا أفلسَت الشركة أو في حالة وجود ديون للشركة أكثر من الأصول بالنسبة للشركة المدينة و يثور نزاع حول حصة الشريك بحيث إذا اعتبرت قرضا فهو يستردها حتما و التفرقة الأساسية تكمن أن الشريك في الشركة يتحمل مخاطرها فهو يستفيد من الربح و يتحمل الخسارة و لا يمكن أن تقوم الشركة على أن لا يتحمل الشريك الخسارة إذ تنص المادة 426 مدني:

"إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة و لا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا. ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجره ثمن عمله".

و هذا يعرف بشرط الأسد.

و تجدر الملاحظة أن حق المراقبة التي يمنح للمقرض أحيانا إذا أصبح من الضمانات غير مسماة التي تمكن المقرض من مراقبة أعمال الشركة و هذا لا يجعل من المقرض شريك ما دام لا يتحمل الخسارة و يسترجع المبالغ المقرضة دون خسارة.

و يثور التساؤل أحيانا بالنسبة لهذا النمط في البنوك الإسلامية. كما يرى بعض المؤلفين: " ويقوم التمويل بالمشاركة أساسا على القاعدة الإسلامية: "الغنم بالغرم". و "الغنم" بالشيء هو الفوز به، والغرم "هو الدين أو أداء شيء يلزم به". وفي الاصطلاح الشرعي: يعنى "الغنم بالغرم" تحميل الفرد من الأعباء، بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، بحيث تتعادل كفتا الميزان.

وفي ذلك تأكيد على حرص الإسلام في تحقيق عدالة التوزيع، وتكافؤ الفرص في العمل، والمشاركة في النشاط الاقتصادي. فالإسلام يرفض المساواة في اقتسام العائد، أو الغنم بين الأفراد، إذا لم يتحقق ابتداء مساواة في المشاركة في المخاطر أو الغرم، وذلك عملا بقول الله تعالى: "لا تظلمون ولا تظلمون" (سورة البقرة 280)

وهذا يبرز أهمية المشاركة في الخسائر لاعتبار المقرض شريكا.

كما أن صاحب سندات الاستحقاق أو المساهمة في الشركات التجارية لا يمكن أن يكون له صفة الشريك، إذا كان له صفة الدائن يسترجع ما اقترضه دون تحمل الخسائر وفقا لنص المادة 715 مكرر 99: " (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993) يجب أن يكون حق التصويت المرتبط بسندات الاستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي تمثله. يمنح كل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل".

القرض و الوديعة:

تنص المادة 590 مدني على ما يلي: "الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولاً إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يردده عينا". إن القرض يسمح للمقرض بالاستعمال سواء أدى استعماله إلى استهلاكه في قرض الاستهلاك أو استعماله و رده عينا كما في قرض الاستعمال أو العارية بينما

الوديعة لا يمكن استعمالها دون إذن من المودع المادة 591 مدني: "على المودع لديه أن يتسلم الوديعة.

و ليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمناً"، كما أنه بالنسبة للوديعة فالالتزام الرئيسي هو المحافظة على الشيء المودع و يرده عينا المادة 590 مدني، و المودع لديه مسؤولاً عن السرقة أو إتلاف شيء و لو أن المشرع فرق في ذلك بين العناية المطلوبة في حالة الوديعة بأجر و الوديعة بدون أجر المادة 592 مدني: "إذا كنت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله.

و إذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوماً أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد". و غالباً الوديعة واجبة الرد عند الطلب فهي من عقود الأمانة فالتصرف فيها يعتبر جريمة من جرائم خيانة الأمانة (المادة 376 من قانون العقوبات).

ويثار التقارب بين الوديعة و القرض بصدد الأشياء القابلة للاستهلاك بحيث نص المشرع في المادة 598 مدني: "إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يستهلك و كان المودع لديه مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً". و المشرع وضع النص عام يخص الوديعة النقدية عموماً، و إذ الأمر يخص صعوبة ردها عينا بالنسبة للنقود بل رد مثيلها فقط.

و لكن اعتبار الوديعة قرضاً يجعل من المودع لديه مالكا و يمكنه التصرف فيها و المقرض أو المودع مجرد دائن و كما لا يمكن في حالة عدم الرد تطبيق النصوص الخاصة بخيانة الأمانة و هذا يعتبر أمر خطير بالنسبة للمقرض فلهذا من المفروض أن يشترط صراحة لتطبيق أحكام القرض أن يسمح باستعمالها في وقت معين و ألا يكون المقرض ملزم عليه بالرد عند الطلب.

كما أن الوديعة النقدية قد تكون على سبيل الضمان في هذه الحالة من المفروض تطبيق أحكام الرهن الحيازي لمبلغ النقود و معالجة بدقة مسألة تملك المودع لديه أو الدائن المرتهن للنقود إلى حين الاسترداد.

فلم ينص المشرع على كيفية إيداع النقود في حساب خاص و لم يتضمن أن الدائن المرتهن يملكها على خلاف تشريعات أخرى تضمنت ذلك بدقة.

و من المستحسن أن لا يغير اعتبار الوديعة النقدية عقد قرض من اعتبارها من عقود الأمانة لتوقيع العقوبة الجزائية على المودع لديه في حالة التقصير العمدي في المحافظة عليها.

فتطبيق قواعد القرض على الوديعة له نتائج مختلفة تماما يجب أن لا نكتف بإمكانية المودع لديه باستعمالها لتكتيف عقد الوديعة أنه قرض وفقا للمادة 598 مدني بل يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين صراحة لذلك و يكف في حالة عدم الاتفاق القول أن الوديعة النقدية لا يلتزم المودع لديه بردها عينا ولكن تنطبق عليها أحكام الوديعة التي لا تتعارض مع طبيعتها.

الدرس الرابع: تنفيذ عقد القرض

تمهيد:

بصدد انعقاد عقد القرض الاستهلاكي في القانون المدني فإن المشرع لم يخصص له نصوص خاصة فتتطبق جميع القواعد العامة في هذا الصدد سواء الخاصة بالتراضي أو عيوب الإرادة أو عوارض الأهلية فتتطبق جميع القواعد العامة في انعقاد العقود و هذه قواعد ثم دراستها ضمن النظرية العامة للعقد لهذا سأعرض للقواعد الخاصة التي تناولها المشرع ضمن نصوص القرض الاستهلاكي فقط.

- و هي تخص التزامات المقرض و المقرض.

أولاً: التزامات المقرض:

1- الالتزام بنقل الملكية:

و قد سبق أن تعرضت لذلك ضمن مميزات عقد القرض فالمقرض يصبح مالكا لمحل القرض فهو يتصرف فيه كيفما شاء لأنه ملزم برد المثل فقط كما أن المقرض يفقد الملكية و تكون له صفة الدائن العادي إذا لم يأخذ ضمان أو صفة الدائن صاحب تأمين إذا تم الاتفاق على أخذ ضمان خاص و يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري انفرد عن باقي التشريعات في عدم إعطاء المقرض الدائن حق امتياز مثلما خص البنوك بذلك كما سنرى رغم أن المقرض قد أضاف قيمة إلى المقرض و المقرض والمفروض أن يكون للمقرض حق امتياز على المال أو العين التي اقتناها المقرض بفضل المال المقرض، و قد نص المشرع الفرنسي صراحة على هذا الحق في المادة 2379 مدني فرنسي التي تسوي في المركز بين البائع صاحب حق امتياز و مقرض الأموال النقدية بهدف تملك العقار.

2- الالتزام بالتسليم:

تنص المادة 451 مدني على ما يلي:

"يجب على المقرض أن يسلم إلى المقرض الشيء الذي يشتمل عليه العقد و لا يجوز له أن يطالبه برد نظيره إلا عند انتهاء القرض.

و إذا تلف الشيء قبل تسليمه إلى المقرض كان الإلتلاف على المقرض."

فالتسليم التزام يلتزم به المقرض و ليس ركنا في العقد كما في القوانين الأخرى إذ لو كان التسليم ركن في العقد لكنا أمام عقد عيني لا ينعقد إلا بالتسليم و هذا ما أخذ به المشرع في عقد الهبة التي محلها منقول و هناك فعلا من يري أن العقد العيني لم يعد له مبرر في القانون الحديث ما عدى في هبة المنقولات نص 206 قانون الأسرة:

"تنعقد الهبة بالإيجاب و القبول، و تتم الحيابة، و مراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات و الإجراءات الخاصة في المنقولات."

و الوديعة نص 590 مدني:

"الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يردده علينا."

و لكن بعض الفقه الفرنسي مازال يؤكد على عينة عقد القرض و ما يبرر ذلك بالنسبة لهم أن التزامات الطرف الآخر هو المقرض لا تنشأ إلا بعد أن ينفذ المقرض التزامه بالتسليم بل يرى البعض أن ذلك يحقق حماية للمقرض في القانون المدني ليدرك خطورة التصرف فيرتبط الإدراك الحقيقي بالتصرف بالتخلي عن محل التصرف فعلا.

مع الملاحظة أن القرض ليس عيني في القانون الفرنسي إذا كانت مؤسسات القرض هي المقرضة و هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي منذ 2006.

و هذه المسائل لا مجال لها في القانون الجزائري الذي يعتبر التسليم التزام يتحمله المقرض و يترتب على التسليم أن تبعة الهلاك تقع على المقرض منذ التسليم إذ تنص المادة 2/451 صراحة بذلك:

" يجب على المقرض أن يسلم إلى المقرض الشيء الذي يشتمل عليه العقد و لا يجوز له أن يطالبه برد نظيره إلا عند انتهاء القرض.

و إذا تلف الشيء قبل تسليمه إلى المقرض كان الإلتلاف على المقرض."

فإذا هلك الشيء المقرض بفعل قوة قاهرة أو سبب أجنبي يلتزم المقرض برد المثل و لا يعفيه ذلك من المسؤولية.

و يلاحظ أن المشرع استعمل "التلف" و هو المقصود "الهلاك" اذ ينص النص الفرنسي على مصطلح " péril "، و إذا كان مصطلح الهلاك يشمل التلف فالعكس غير صحيح فإن التلف قد ينقص القيمة دون هلاك.

3- الالتزام بضمان الاستحقاق:

تنص المادة 452 مدني على ما يلي:

"إذا استحق الشيء فإن أحكام المادة 538 و ما بعدها و الخاصة بالعارية هي التي تطبق."

و في المادة خطأ مادي في رقم المادة المحال إليها فهي المادة 541 بصدد العارية.

و يلاحظ أن الربط بين المادتين في ضمان الاستحقاق سببه مجانية كلا العقدين فلا يمكن تحميل المقرض تبعة استحقاق الشيء إلا في حالة الاتفاق السريع أو أن يكون المقرض قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، إذ تنص المادة 1/541 مدني على:

"لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب نزع اليد.

ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك."

4- التزام ضمان العيوب الخفية:

تنص المادة 453 مدني على ما يلي:

"إذا ظهر في الشيء عيب خفي و اختار المقرض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء المعيب.

أما إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فللمقرض أن يطلب إما إصلاح العيب أو استبدال الشيء المعيب بشيء خال من العيوب."

و يثور التساؤل عن محل القرض الذي يمكن أن يسلم معيبا فقد تكون بذور أو سماد كم قد تكون آلات ثم إنتاجها بالسلسلة فهي تأخذ حكم المثليات، يمكن أن تأخذ محل قرض و ينطبق عليها حكمه.

و الملاحظ أن المشرع يتضمن حكم استثنائي في هذه الحالة، أنه إذا اختار المقترض تسلم شيء معيبا فهو غير ملزم برد مثله بل يرد قيمته فقط، و هذه الحالة المفروض تعميمها في جميع الحالات التي يستحيل فيها رد المثل لتعذر وجوده في السوق، و يلاحظ أن المشرع لم يحيل إلى النص الخاص بالعارية و هو نص المادة 2/541 الذي يتضمن ما يلي:

"لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب نزع اليد.

ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك."

إذ الاحتمال وارد أن يلحق بالمقترض أضرار بسبب العيب و في هذه الحالة تطبق القواعد العامة بصدد التعويض.

ثانيا: التزامات المقترض:

- الالتزام الواقع علي عاتقه هو الرد في النوع و القدر و الصفة حسب المادة 450 مدني (راجع المادة 95 مدني).

- في حالة اختلاف الطرفين في الصنف (01 يقول صنف جيد، و الثاني يقول صنف رديء) هنا نرجع للقواعد العامة أي تسليم الصنف المتوسط. (لهذا وجب تدوين الصنف في العقد).

- بند الذهب ممنوع: وهو رد نفس القيمة النقدية ذهباً فهو بند باطل لأن القرض دون فائدة بين الأفراد و هذا تطبيقاً للشريعة الإسلامية فالفائدة في القانون المدني تعتبر ربا.

و يرد المقترض الشيء الذي أقرضه إليه المقرض في المدة المتفق عليها في العقد. وإذا لم يتفق على مدة ووقع نزاع، في هذه الحالة تحدد هذه المدة عن طريق العرف السائد و المتعامل به.

- فإذا حددت المدة في العقد (عقد القرض) لا يمكن المطالبة بالاسترداد قبل الآجال، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 211 مدني.

المادة 211 مدني:

"يسقط حق المدين في الأجل:

- إذا شهر إفلاسه وفقا لنصوص القانون.
- إذا أنقص بفعله لحد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص ...
- إذا لم يقدم للدائن ما وعد بتقديمه من تأمين."

و يلاحظ أن المادة 211 مدني تعرضت للإفلاس و هو توقف التاجر عن تسديد ديونه التجارية فيصدر الحكم بالإفلاس و يشهر وفقا لنص المادة 215 الى 388 قانون تجاري.

و لم تتعرض المادة للإعسار المدني و ذلك لأن المشرع الجزائري لم ينظمه بنصوص خاصة، على عكس عدة تشريعات التي نظمته بدقة و إن كان المشرع تعرض للإعسار في المواد 191 إلى 197 من القانون المدني فهو فقط إشارة إلى إعسار فعلي للمدين بتوقفه عن ديونه المدنية و لكن لم ينظمه على غرار ما فعل في القانون التجاري مما يترتب عليه أن الشخص المقرض قد يقرض مال إلى شخص في حالة إعسار دون علمه لعدم وجود شهر لحالة الإعسار مما يصعب معرفة الوضعية المالية للمقترض و هذا يترتب عليه مخاطر بالنسبة للمقرض في حالة عدم تسديد المقترض للدين لأن شروط تطبيق دعوى عدم نفاذ التصرف تتطلب أن تكون تصرفات المدين لاحقه لاستحقاق الدائن للمدين أي حلول أجل دين شرط ضروري لرفع دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البوليسية أو البوليانية.

و يلاحظ أنه إذا حل آجال تسديد القرض يلتزم المقرض بالتسديد و في حالة نزاع يمكن للقاضي منح آجال إذ تنص المادة 281 مدني على ما يلي:

"يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين، و مراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا أجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة و ان يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها.

و في حالة الاستعجال يكون منح الآجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

و في حالة إيقاف التنفيذ فإن الآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، بصحة إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي."

و هذا يعرف بنظرية الميسرة المستمدة من الشريعة الإسلامية فقد جاء في القرآن الكريم سورة البقرة آية 280 "... فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"، فيمنح له آجال إلى أن يصير موسر و لكن نص المادة 281 مدني ينص على مدة سنة لا يمكن أن يتجاوزها القاضي.

ويلاحظ أن نظرية الميسرة موجودة في التشريعات الغربية أيضا و هذا لتأثر القانون الغربي بالقانون الكنسي فأدرجت بعض القواعد الأخلاقية من ذلك نص المادة 1244/1 قانون مدني فرنسي على ذلك صراحة.

ويلاحظ أن القواعد العامة تجبر للأطراف الاتفاق على بند الجزائي و هذا ما نص عليه المشرع صراحة في المادة 184 مدني:

"لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

و يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

و يكون باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاه."

و المادة 185 مدني: تنص صراحة على السلطة التقديرية للقاضي في تعديل البند الجزائي إذ تنص على ما يلي:

"إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا، أو خطأ جسيما."

أما بصدد فوائد التأخير فتخضع للمادة 186 مدني التي تنص على ما يلي:

"إذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى و تأخر المدين في الوفاء به، فيجب عليه أن يعرض للدائن الضرر إلا حق من هذا التأخير."

و هذا النص انفرد به المشرع الجزائري عن باقي التشريعات التي تجبر أخذ فوائد التأخير بصدد القروض بين الأفراد و ذلك لاعتبار أن الفائدة جائزة في هذه القوانين.

بينما المشرع الجزائري ربط بين فوائد التأخير و الضرر إذ لا يجيز التعويض على مجرد مرور الزمن باعتبار القرض مجاني، فكلما جاوز مبلغ الرد، مبلغ القرض اعتبرت الزيادة باطلة فالمشرع الجزائري يبطل الفوائد التعويضية و يربط الفوائد التأخيرية بين الأفراد بالضرر.

الدرس الخامس: انقضاء عقد القرض في القانون المدني

إن عقد القرض ينقضي بالوفاء.

و ينقضي عقد القرض إذا لم يتم الوفاء بأسباب انقضاء أو سقوط الحق الواردة في القواعد العامة.

المواد 285 إلى 322 من القانون المدني و أ تعرض لأهم هذه الأسباب وأكثرها شيوعا في إطار عقد القرض و هي التقادم، المسقط، الإبراء و المقاصة.

1- التقادم:

يسقط حق المقرض بالتقادم بمرور 15 سنة المادة 308 مدني كما نص المادة 309 مدني بتقادم ب 5 سنوات للدين المتأخرة و لكن إذا حرر سند بذلك فلا تقادم إلا بمرور 15 سنة، المادة 313 مدني.

مع الملاحظة أن التقادم يرد عليه الوقف و الانقطاع الوارد في القواعد العامة.

و لكن انقضاء الدين بالتقادم لا يمنع الشخص أن يؤديه إذ يصيرا التزاما طبيعيا فهو غير مجبر على تنفيذه و لكن لا يسترد ما دفعه في حالة تنفيذ اختيارا وفقا للمادة 162 مدني:

"لا يسترد المدين ما أداه باختياره، بقصد تنفيذ التزام طبيعي."

1.1- وقف مدة التقادم:

يتعرض التقادم أثناء سريانه إلى عقبة الوقف، و قد يقف لسبب معين و يؤدي هذا الوقف إلى عدم حساب المدة التي توقف فيها التقادم إذ تحسب المدة السابقة للوقف و تضاف إلى المدة اللاحقة له، ووقف التقادم ليست له مدة معينة فقد يتم في بداية التقادم، مثال ذلك أن ترد الحيازة مند بدايتها على عقار مملوك لقاصر ليس له ممثله القانوني، فيقف التقادم إلى حين بلوغ القاصر سن الرشد، كما قد يقف التقادم بعد بدء سريانه.

ووقف التقادم أمر اقتضته العدالة بحيث يقف لصالح أشخاص تعذر عليهم رفع الدعوى في مدة زمنية معينة لأسباب معينة.

و لقد نص المشرع الجزائري على وقف التقادم كلما وجد مانع لدى المالك و ذلك بمقتضى المادة 1/316 مدني جزائري:

"لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل و النائب."

أ/ أسباب وقف التقادم:

يمكن تقسيم أسباب وقف التقادم إلى نوعين:

أسباب راجعة إلى ظروف خارجية و أسباب راجعة للشخص ذاته من أهلية، و نوع الرابطة التي تربط بالحائز.

فأسباب وقف التقادم التي ترجع إلى الظروف الخارجية لم يحددها المشرع الجزائري، ذلك لأنه يطبق القاعدة العامة التي تنص على وقف التقادم كلما وجد عند صاحب الحق مانع، و الموانع ترجع إلى ظروف خارجية قد تكون حربا مثلا أو نشوب فتنة فيؤدي هذا الظرف إلى عدم تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه أو منع المحاكم من مباشرة أعمالها و لقد اعتبر القضاء الجزائري الحرب التحريرية سببا لوقف التقادم.

و قد يكون المانع الذي يمنع الشخص من وقف التقادم مانعا أدبيا يرجع إلى قيام علاقة الزوجية أو القرابة بين الحائز و المالك فوجود هذه العلاقة مثلا يعتبر مانعا أدبيا من المقاضاة .

وقد يكون المانع قانونيا كحالة اتحاد الذمة فإذا أصبح الحائز مالكا لفترة من الزمن ثم زال اتحاد الذمة لسبب من الأسباب فإن المدة التي قام خلالها اتحاد الذمة لا تدخل في مدة التقادم.

ب/ آثار وقف التقادم:

يترتب على وقف التقادم إسقاط المدة التي وقف التقادم خلالها من حساب مدة التقادم و ذلك سواء وقع سبب الوقف في بداية التقادم أو أثناء سريانه أو في نهايته.

و أسباب وقف التقادم نسبية فلا ينتفع بها إلا الشخص الذي وقف التقادم لمصلحته و لكن هناك استثناء في حالة ما إذا كان الحق الذي ترد عليه الحيازة غير قابل للتجزئة كحق الارتفاق إذ يقف التقادم بصفة مطلقة في حق جميع الشركاء.

2.1- انقطاع مدة التقادم:

و الانقطاع هو العقبة الثانية التي تعترض التقادم، و انقطاع التقادم يعني سقوط مدته نهائيا بسبب معين مذكور في القانون، و يبدأ بعدها تقادم جديد لا تحتسب فيه المدة التي سبقت الانقطاع، و هذا ما يميز انقطاع التقادم عن وقفه، إذ أنه بالنسبة لوقف التقادم تحسب فيه المدة التي سبقت الوقف.

و انقطاع التقادم على نوعين، انقطاع طبيعي و انقطاع مدني و قد نص المشرع الجزائري على الانقطاع الطبيعي في المادة 834 مدني كما نص على الانقطاع المدني في المواد 317 إلى 319 مدني جزائري.

و سأتناول الانقطاع المدني لأن الانقطاع الطبيعي لا يهم الموضوع.

- الانقطاع المدني: إن الانقطاع المدني للتقادم يكون صادرا إما من المالك و أما من الحائز، و سأتناول أولا، الانقطاع المدني الصادر من المالك، ثم الانقطاع المدني الصادر من الحائز.

الانقطاع المدني الصادر من المالك:

تنص المادة 317 مدني جزائري على ما يلي:

"ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز، و بالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسه المدين أو في توزيع أو بأي عمل يوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه."

و الذي يهمنا فيما يتعلق بالتقادم المكسب هو انقطاعه بالمطالبة القضائية و بالتنبيه أما الطرق الأخرى فهي خاصة بالتقادم المكسب هو انقطاعه بالمطالبة القضائية و بالتنبيه أما الطرق الأخرى فهي خاصة بالتقادم المسقط.

انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية:

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و ذلك راجع لاعتبارها تقتضيها العدالة، لأن الدعوى قد يطول الفصل فيها و ليس من العدل أن يسري التقادم أثناء سريان الدعوى و قبل الفصل فيها لأن الأحكام المقررة للحق تسري بأثر رجعي من يوم بداية المرافعة.

و ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية أي مطالبة صاحب الحق بحقه، و يستوي أن تكون هذه المطالبة بدوى أصلية أو بطلب عرض أثناء نظر الدعوى أو عن طريق اختصام الغير أو التدخل.

و ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة و ذلك لأن القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي قد تكون معقدة يتعذر على المدعى تبينها.

و لا تكفي لقطع التقادم المطالبة أمام قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء وقتي لا يمس موضوع الحق، فالمفروض لقطع التقادم أن ترفع دعوى عن موضوع الحق أي دعوى الاستحقاق.

و لكن إذا رفعت الدعوى بأصل الحق أمام قاضي الاستعجال فرفع مثل هذه الدعوى يقطع التقادم لأنه يكون عبارة عن رفع دعوى بأصل الحق و لكن أمام محكمة غير مختصة، و قد سبق القول بأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم.

و لكي ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية يجب أن تنتهي الدعوى بحكم لصالح المدعي، أما إذا سقط الدعوى أو رفض الفصل فيها فلا ينقطع

فلا يهم أن يكون سبب فرض الدعوى راجعا إلى سبب موضعي أو إلى سبب شكلي فأى رفض للدعوى يؤدي إلى إلغاء انقطاع التقادم. و يعتبر الانقطاع كأن لم يكن و يبقى التقادم ساريا.

انقطاع التقادم بالتنبيه:

إذا كان بيد صاحب الحق سند تنفيذي و هو إما حكم أو سند رسمي فإنه لا يرفع دعوى على الحائز و إنما يسارع إلى تنفيذ بناء على السند الرسمي أو الحكم، و لكن ألزم المشرع الجزائري في المادة 330 إجراءات مدنية بأن يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه و يكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما، و من مشتملات السند التنفيذي التنبيه.

و يري معظم الشراح أن التنبيه خاص بالتقادم المسقط فقط إذا أن التنبيه يوجه إلى المدين.

غير أن جانبا آخر من الفقه يرى أنه من المتصور أن يقطع التقدم المكسب بالتنبيه، وذلك كما لو كان بيد المالك حكم ضد الحائز بترك العقار فيوجه إليه تنبيهها بالإخلاء قيل أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري. ورأي أن هذا الرأي أجدر بالتأييد و لنفس السبب أرى أنه من المتصور و الممكن أن يقطع التقدم المكسب بالتنبيه.

انقطاع التقدم بفعل المدين:

إن الانقطاع المدني قد ينتج عن إقرار الحائز فقد نصت المادة 318 مدني جزائري على ما يلي:

"يتقطع التقدم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا و يعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن ما لا له مرهونا و هنا حيازيا تأمينيا لوفاء الدين."

و قد عرفت المادة 341 مدني جزائري الإقرار على النحو التالي:

"الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوي المتعلقة بها الدعوى."

فالإقرار تصرف قانوني و هو ليس نزولا عن الحق بل يعتبر نزولا عما انقضي من مدة فقط ذلك لأن الحائز لم يكسب بعد هذا الحق ليعتبر متنازلا عنه و الإقرار يتم بالإرادة المنفردة أي إرادة الحائز وحدها و لا يجوز للحائز سحب إقراره، و بالخصوص الأهلية المتطلبة في المقر اختلف الرأي، فهناك من لا يشترط أن تكون لدي المقر أهلية التصرف و يبررون موقفهم بأن الإقرار لا يعتبر تصرفا في الحق إذ مدة التقدم المتطلبة لاكتساب الحق لم تكتمل بعد.

و لكن أغلب الفقه يذهب إلى اشتراط توفر أهلية التصرف لدي المقر لأن إقرار الحائز قطع التقدم، و لو لم يقطعه و اكتملت مدته لأدى الى تملك الحائز للعين، فالإقرار عبارة عن نوع من التصرف في العين.

و لا يشترط في الإقرار شكل معين، فقد يكون صريحا أو ضمنيا، و الإقرار الضمني قد يستخلص من مجرد السكوت أحيانا أو من أية عبارة عن صادرة من الحائز.

2- الإبراء:

ينقضي الحق أيضا بالإبراء إذ تنص المادة 305 مدني على ما يلي:

"ينقضي الالتزام إذا برأ إذا برأ الدائن مدينه اختياريا و يتم الإبراء متي وصل إلى علم المدين و لكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين."

و نظرا لخطورة الإبراء فالمشرع أخضعه لأحكام عقود التبرع، و هذا ما تضمنته المادة 306 مدني:

"تسري على الإبراء الحكام الموضوعية التي تسري علي كل تبرع.

و لا يشترط فيه شكل خاص و لو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرصة القانون أو اتفاق عليه المتعاقدان."

مع الملاحظة أن المشرع نص في المادة 305 مدني انه في حالة رفض المدين الإبراء يصبح باطلا و لكن الجزاء هو الإلغاء إذ النص الفرنسي يتضمن " caduque"، و لأن البطلان يخص عدم توافر ركن من أركان العقد.

3- المقاصة:

المقاصة كطريقة وفاء يلجأ إليها كثيرا في عقد القرض و إذا تمت المقاصة بين دين للمقرض مع المقرض، إذا كان كلاهما مدينا و دائنا للآخر فينقضي الدين، و ينص المشرع في المادة 297 على ما يلي:

"للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له اتجاهه و لو اختلف سبب الدينين إذ كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع و الجودة و كان كل منهما ثابت و خاليا من النزاع و مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء.

و لا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن."

و تظهر في المقاصة أهمية التفرقة بين قبول حوالة الحق و الإعلان بها إذ تنص المادة 303 مدني على ما يلي:

"إذا حول الدائن حقه للغير و قبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا الأخير أن يتمسك قيل المحال له بالمقاصة التي كان تمسك بها قبل قبوله للحوالة و ليس له إلا الرجوع بحقه على المحيل.

أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة و لكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة."

و يلاحظ أن جميع أسباب انقضاء الدين الواردة في القواعد العامة تنطبق في هذا المجال مادام المشرع لم ينص على نص خاص بصدها.

انتهاء عقد القرض لوفاة المقترض:

إن وفاة المقترض قد تجعل الدين حالا، ذلك إذا لم يوجد نص خاص بخلاف ذلك و ذلك وفقا للقاعدة الشرعية "لا تركة إلا بعد سداد الديون، إذ تنص المادة 180 قانون الأسرة على ما يلي:

"يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:

1. مصاريف التجهيز، و الدفن بالقدر المشروع،
2. الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
3. الوصية."

فلا يلزم الورثة بدين المورث من الناحية القانونية و على المقترض أن يتقدم إلى تركة المتوفى و يأخذ حقه من التركة، و في حالة استغراق التركة بالديون فلا يلزم الورثة بتسديد المورث إلا في حالات وجود نصوص تسمح بذلك و هذا استثناء إذا كان الدين مرتبط بعقار انتقل إلى الوارث مثل سكنات "عدل".

مسألة إنهاء المقترض عقد القرض مسبقا:

تتعرض التشريعات لمسألة إمكانية دفع المقترض لمبلغ القرض مسبقا و هذا حق من حقوق المقترض إذا كان له صفة المستهلك كما سنرى و لكن في إطار القانون المدني تنص المادة 458 مدني على ما يلي:

"يجوز للمدين إذا انقضت ستة (6) أشهر على القرض أن يعلن رغبته في انعقاد القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد، و رد ما اقترضه على أن يتم ذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلان.

أما حق المقرض في الرد فإنه لا يجوز إسقاطه أو تحديده بمقتضي الاتفاق."

و المفروض أن المقرض يمكنه الإنهاء دون قيد و لا شرط باعتبار أجل القرض
تقرر لمصلحته، و لا ضرر يلحق المقرض من الإنهاء المسبق فالمادة 458 مدني
لا مبرر لها و الشروط المدرجة فيها أيضا بينما نجد بعض رسائل دكتوراه تدرج
هذه المادة بل تطبقها على القروض البنكية و هذا غير مقبول و سنتعرض لهذا
لاحقا.